

1521657-50.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... as drogas, anotações referentes ao tráfico etc.) que pudesse corroborar a imputação pela prática do tráfico de drogas pelo acusado. Corroborando a imputação de tráfico de entorpecentes, somente há a quantidade pequena de entorpecentes e as palavras confusas entre si dos policiais militares quando ouvidos em juízo acerca da abordagem do acusado. Por fim, necessário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 11 2868 - 7154, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1521657-50.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO NEVES DE SOUZA e outro

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

14/12/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

No dia 14 de dezembro de 2.022 às 13h35min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). ALESSANDRA ANDREZ C. J. BOROWSKI

Réu: DIEGO NEVES DE SOUZA (Réu preso)

Defensor(a) Público(a): Dr(a). CAROLINA LEITE LOPEZ DE LEON
Réu: FÁBIO MAGALHÃES DA SILVA (Réu preso)
Advogado: Dr. CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Testemunha/A: IGOR VIANNA DA SILVA
Testemunha/A: KAIQUE JOSÉ FÉLIX DA SILVA
Testemunha/D pelo corréu FÁBIO: JUCILENE ARLINDA DE AMARAL
Testemunha/D pelo corréu FÁBIO: EDUARDO MAURÍCIO DE BRITO
Ausente(s):
Testemunha/D pelo corréu FÁBIO: PAULO ROGÉRIO DILERMANDO GARCIA

Instrução

Preliminarmente, pelo MM. Juiz foi dito que: Tendo em vista que se trata de processo-crime de réus presos, entendo que a ausência de algemas trará risco principalmente aos funcionários da unidade penitenciária, sobretudo àqueles incumbidos das tratativas que envolvem as videoconferências, que perambulam entre presos constantemente, sem qualquer divisa física entre servidores e custodiados. Outrossim, cumpre assinalar que se houve a manutenção das algemas pelos funcionários e direção técnica daquele prédio carcerário, é porque há juízo de confiabilidade quanto a sua imprescindibilidade no caso. Portanto, a ausência de tais adereços mostra-se temerária e o seu uso se revela essencial à ordem dos trabalhos, mesmo que exercidos de forma telemática. Dessa forma, para garantir a integridade física daqueles presentes na sala de apresentação dos presos, determino que os réus permaneçam algemados. Nada mais.

Preliminarmente, os acusados foram notificados em audiência nesta data. DIEGO desejou a nomeação dos Defensores Públicos atuantes nesta Vara, o que foi deferido pelo MM. Juiz de Direito.

Pela Defensora Pública foi dito que: MM. Juiz, da análise dos autos, contata-se que não há elementos satisfatórios para caracterizar a propriedade da droga apreendida e tampouco a intenção por parte do(a) acusado(a) de fornecê-la para terceiros. Não resta evidente, portanto, a justa causa para a instauração da ação penal. Contra o(a) acusado(a) há apenas depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, pessoas naturalmente parciais e com interesse no desate do feito. Assim, indiscutível a rejeição da denúncia. Ante todo o exposto, requer-se a REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, tendo em vista toda a fundamentação fática e jurídica acima declinada. Não sendo esse o entendimento, arrolar como testemunhas aquelas arroladas pela acusação, protestando por ulterior substituição ou complementação do rol, se necessário.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. Não foram suscitadas matérias preliminares ou prejudiciais de mérito, nem antecipadas teses defensivas. As teses defensivas apresentadas dizem respeito ao exame da prova colhida na prova policial, sendo necessário, porém, para melhor análise, a instrução probatória em juízo, sob o crivo do contraditório. Outrossim, cuidando-se de juízo de admissibilidade da denúncia, inviável, nesta fase, acolher de imediato, as teses suscitadas na defesa prévia, as quais adentram na valoração da prova e se confundem com o mérito da ação penal, motivo pelo qual serão apreciadas no momento oportuno, quando do julgamento da ação penal, após a regular instrução probatória. No momento, em cognição sumária, da análise perfunctória dos elementos de prova colhidos na fase policial e das circunstâncias que cercaram a prisão dos acusados, verifica-se que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se podendo afastar, de imediato, a finalidade da traficância. Portanto, há justa causa para o prosseguimento da ação penal, sendo inviável, rejeitar a denúncia ou desclassificar, de plano, a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Nestes termos, havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como havendo justa causa para o exercício da ação penal, não havendo motivos que imponham a rejeição da denúncia e afastadas as

hipóteses do art. 395 e seus incisos do Código de Processo Penal e, deste modo, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, RECEBO A DENÚNCIA formulada em face de DIEGO NEVES DE SOUZA, dando-o(a) como incurso(a) no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Cite-se.

Por conferir melhor exercício ampla defesa, será adotado o rito ordinário, interrogando-se somente ao final da instrução. Assim sendo, confirmo a audiência reservada para esta data.

Os réus foram citados em audiência.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas e, após, realizado o interrogatório do réu, todos em audiovisual.

A defesa desistiu das oitivas das testemunhas de defesa, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

A manifestação do Ministério Público se deu em audiovisual.

Pela Defensoria Pública pelo corréu DIEGO foi dito que: MM. Juiz, reitero a manifestação ministerial.

Pela Defesa do corréu FABIO foi dito que: MM. Juiz, considerando a confissão espontânea do réu, esta Defesa passa a formular somente os seguintes pedidos: aplicação das penas-base nos seus patamares mínimos legais, considerando a sua primariedade e ausência de antecedentes desabonadores, reconhecimento da confissão como atenuante genérica, aplicação do redutor previsto no parágrafo quarto do art. 33, da Lei n. 11.343/06, fixação de regime diverso do fechado, bem como a sua aplicação na fração máxima (2/3) e, por fim, direito de recorrer em liberdade.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. DIEGO NEVES DE SOUZA, qualificado à pág. 17 e FABIO MAGALHAES DA SILVA, qualificado às págs. 18 e 59, viram-se denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, porque, no dia 21 de setembro de 2022, por volta da 1h10, na Rua São Lucas, altura do n. 10, bairro Jardim São Francisco, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de propósitos, guardavam e traziam consigo, para fins de tráfico, 74 porções de maconha (194g), 50 frascos de lança-perfume (500 mililitros), 129 porções de cocaína em (80,2g) e 146 porções de crack (25,9g), consoante auto de exibição e apreensão de fls. 19 e laudo de constatação de fls. 21/24, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Segundo narra a denúncia, os denunciados postaram-se no local dos fatos trazendo diversas porções de maconha, cocaína em pó, crack e lança-perfume, acondicionadas em uma sacola plástica, visando praticar o comércio de entorpecentes. Policiais militares que faziam patrulhamento pelo local, conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram os denunciados, sendo que FABIO estava segurando a sacola plástica preta nas mãos. Os denunciados, ao perceberem a presença da equipe, correram em direções opostas. Durante a fuga, FABIO dispensou a sacola plástica ao chão, e na sequência os denunciados foram alcançados e contidos. No interior da sacola dispensada por

FABIO, os policiais localizaram 74 invólucros de maconha, 50 frascos contendo lança-perfume, 129 porções de cocaína em pó e 146 porções de crack. Efetuada busca pessoal, com DIEGO foram localizados 04 invólucros de maconha, 03 porções de cocaína em pó e 03 pedras de crack (cf. fls. 3 e 5). Diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos ao Distrito Policial. Interrogados, DIEGO (fl. 6) e FABIO (fl. 7) negaram os fatos, alegando que são usuários de drogas. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, individualmente embalados e prontos para a venda, bem como as circunstâncias da abordagem policial, efetivada após fuga dos denunciados, evidenciam que as substâncias eram destinadas ao comércio ilícito. Presos em flagrante, em sede de plantão criminal foi reconhecida a regularidade de suas prisões, sendo estas convertidas em preventivas. Os denunciados foram notificados, nos termos do artigo 55, da Lei 11.343/2006, sendo oferecidas defesas prévias. Afastadas as hipóteses de rejeição liminar, a denúncia foi recebida, confirmando-se e designando-se audiência de instrução, debates e julgamento previamente agendada. Os acusados foram citados. Durante a instrução, foram ouvidos os policiais militares e, após desistência homologada das demais oitivas, foram realizados os interrogatórios dos acusados. Superada a fase do art. 402 do CPP e declarada encerrada a instrução probatória, sobrevieram debates orais. O Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, condenando-se FÁBIO pela prática prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Com relação ao corréu DIEGO, seria o caso de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, com a aplicação da detração anômala. A Defensoria Pública representando o corréu DIEGO, por seu turno, reiterou a manifestação ministerial. A d. Defesa pelo corréu FÁBIO, por derradeiro, formulou pedidos atinentes à dosimetria das penas. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE, devendo o acusado FÁBIO ser condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, do Código Penal, enquanto a conduta do acusado DIEGO melhor se amolda ao delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, inexistindo prova segura e concludente da finalidade da traficância, devendo vigorar, no caso, o princípio do in dubio pro reo. Com efeito, o conjunto probatório é insuficiente para reconhecer a finalidade da mercancia, não bastando, no caso, a quantidade apreendida em poder do acusado para reconhecer a traficância. Nestes termos, A materialidade delitiva é incontestada e vem estampada no auto de exibição e apreensão, laudo de constatação, bem no laudo de exame químico-toxicológico, que resultou positivo para cocaína, maconha e tricloroetileno. A autoria é certa e indubitável, havendo prova segura e suficiente para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Em juízo, o réu FABIO confessou a prática do crime. FÁBIO MAGALHÃES DA SILVA, interrogado em juízo, afirmou que estava com a sacola com as drogas. Estava traficando no local. Correu com a sacola. Não correu, na realidade, por causa de uma cirurgia. DIEGO veio comprar. Tem 1 (um) filho. Está no primeiro ano do ensino médio. Está envergonhado. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida. (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel.

Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018). De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de tê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379). Tem-se que a confissão dos acusados não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288). É dizer: as confissões têm valia, ainda mais porquanto corroboradas pelo restante da prova produzida, sendo aptas a fundamentarem a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a desconsideração de qualquer delas. Corroborando as confissões espontâneas dos acusados, temos as coesas palavras dos policiais militares que participaram de suas prisões. O policial militar Igor Vianna, ouvido em juízo, afirmou que estavam em patrulhamento pela via, que já é conhecida como ponto de venda de drogas e, em determinado momento, aproximaram-se dos dois acusados, ambos correram, cada um para um lado. O depoente conseguiu deter o FÁBIO, que estava com uma sacola na mão, a qual foi dispensada por ele, de cor preta, enquanto o seu colega de farda conseguiu pegar o corréu DIEGO. Maior parte das drogas estava na sacola com FÁBIO. Havia maconha, cocaína, crack e lança-perfume. Posteriormente, com DIEGO foram encontrados 4 papelotes de maconha, 3 pinos de crack e 3 de cocaína. A princípio, tinham falado que só estavam utilizando drogas e correram, pois se assustaram. Foi patrulhamento, não fizeram campana. Não foi encontrado dinheiro. Nenhum dos 2 (dois) assumiu a traficância. Os 2 (dois) falaram que estavam usando drogas apenas. A forma de embalagem era a mesma tanto das drogas encontradas com FÁBIO como com DIEGO. Não sabe precisar se já avistou os denunciados por lá, pois faz patrulhamento constantemente pela região. Nesse momento, não havia ninguém na rua. Estavam de viatura. Não sabe precisar a distância que estava dos denunciados quando eles correram, mas foi de uma distância próxima. Eles estavam sentados numa escada, que tem na via. Não chegou a flagrá-los em venda de entorpecentes. O policial militar Kaique José Felix da Silva, em juízo, relatou que estavam em patrulhamento pelo local, já conhecido como ponto de venda de produtos ilícitos, avistaram dois indivíduos, no final da rua, os quais, ao avistarem o depoente e o seu colega, empreenderam fuga, cada um para um lado. O depoente conseguiu deter DIEGO. FÁBIO dispensou uma sacola preta. Em revista pessoal com FÁBIO, nada de ilícito foi encontrado, mas na sacola foram encontradas drogas. Com DIEGO foram encontrados 4 papelotes de maconha, 3 pinos de crack e 3 de cocaína. FÁBIO estava com a maior parte das drogas, DIEGO estava com uma quantidade de entorpecentes talvez compatível com a condição de usuário. Ambos afirmaram que eram usuários. Não viram atos de venda. Os dois estavam no final da rua. Os 2 (dois) estavam em pé. Cada um correu para o lado. FÁBIO estava portando uma sacola. DIEGO veio na direção e FÁBIO correu para outro sentido. Nunca viu o 2 (dois) denunciados. Não havia anotação de entorpecentes. Não havia pessoas passando no local. Aos depoimentos policiais também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,

mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. SouzaNery, j. 27/08/2015). Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice. Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos, sobretudo as confissões espontâneas dos acusados em juízo. A prova produzida nos autos é segura e conclusiva, sendo apta a autorizar o decreto condenatório. Dá-se o crime de tráfico ilícito de drogas quando o agente pratica um dos núcleos do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a realização de um único verbo do tipo para a adequação da conduta. No caso, o réu FABIO trazia e guardava para a entrega ilícita ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, para entrega a consumo de terceiro. Os fatos narrados na denúncia subsumam-se perfeitamente à descrição legal. Assim, diante da quantidade de entorpecente encontrado na ocasião, a variedade e a forma de acondicionamento da droga, são fatores que reunidos permitem obter a certeza FÁBIO praticou a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Dessa forma, mister se faz a sua condenação. Por outro lado, com relação ao réu DIEGO NEVES DE SOUZA, interrogado em juízo, nega a prática do crime. É usuário, estava saindo e foi abordado. Estava com essas porções mesmo em seu poder. Está arrependido. Estava há 2 (dois) anos na rua. A versão trazida pelo acusado revela-se crível e coaduna com o restante dos elementos dos autos e ganha força, reprimido, em razão da evidente contradição entre os depoimentos policiais judiciais. Não se questiona a validade e o importante valor probatório do depoimento dos policiais em sede de repressão ao comércio clandestino de entorpecentes, como vem decidindo reiteradamente a jurisprudência. Contudo, tal orientação vem encontrando resistência no seio dos Tribunais, em face de fundadas suspeitas de maus policiais, que vêm forjando flagrantes com os mais inconfessáveis propósitos. Ademais, quando na apuração do evento delituoso, a prova resulta, exclusivamente, dos depoimentos de policiais e estes se mostram sem a necessária segurança e precisão, a dúvida daí resultante conduz à absolvição. Nesse sentido, já se decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "TRÁFICO DE DROGAS - Quadro probatório que se mostra frágil a comprovar a destinação mercantil da droga apreendida Admissão da propriedade da droga pelo réu, dizendo ser para consumo próprio Contradição entre os depoimentos dos policiais destacada pelo d. magistrado Quantidade da droga apreendida em imóvel compatível com a destinação para consumo próprio (112g de maconha em 5 porções e 2g de cocaína em 3 porções) - Prova frágil quanto à acusação de tráfico Ausência da imprescindível certeza para a condenação Acerto da r. sentença desclassificatória para o art. 28, da lei antidrogas Desclassificação mantida Recurso improvido - (voto n. 24542)." (TJSP; Apelação Criminal 0010574-44.2013.8.26.0126; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/03/2015; Data de Registro: 25/03/2015). Além disso, não houve situação de flagrância de qualquer ato característico do comércio ilícito e, com o corréu DIEGO, foram apreendidas poucas porções de entorpecentes, condizentes com a sua condição de usuário. Ademais, é cediço que a quantidade de substância entorpecente ilícita apreendida pode ser considerada para a formação do juízo de valor quanto à existência ou não do crime de tráfico, já que muitas vezes não se consegue flagrar o ato mercantil. Contudo, no caso em tela, a quantidade revelou-se baixa e, ainda, há falta de variedade, autorizando crer que a versão exculpatória do acusado é verossímil, consubstanciada na tese de que as drogas seriam para consumo próprio. Nesse contexto, o legislador, ao redigir o § 2º do retromencionado art. 28, indicou ao intérprete critérios objetivos e subjetivos para determinar, no caso concreto, a correta subsunção do

comportamento do agente. - "§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.". Ou, na lição de Luiz Flávio Gomes e coordenados (Nova Lei de Drogas Comentada, RT, 2006, p. 132): "em outras palavras, são relevantes: o objeto material do delito (natureza e quantidade da droga), o desvalor da ação (local e condições em que ele se desenvolveu), assim como o próprio agente do fato (suas circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes)". Em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado, os critérios indicados assumem natureza de sugestão ao magistrado, não sendo, assim, suficiente a valoração da quantidade de droga apreendida para afastar a sua destinação para uso próprio. Neste sentido, já decidiu a C. STJ: AGRADO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL RECONHECIDO NA ORIGEM. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FATORES NÃO DETERMINANTES QUE DEVEM SER VALORADOS COM OS DEMAIS INDICATIVOS DO § 2º DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. ENUNCIADO 7/STJ. AGRADO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu, após percuente exame do arcabouço probatório, que, apesar da quantidade (70,7 gramas de cocaína), a substância entorpecente apreendida era destinada ao uso do agravado. 2. O legislador, ao redigir o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, indicou ao intérprete critérios objetivos e subjetivos para determinar, no caso concreto, a correta subsunção do comportamento do agente. Destarte, a quantidade e natureza da substância entorpecente são fatores relevantes para delimitação do destino da droga, não tendo, contudo, o poder de suprimir os demais critérios designados local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente. 4. Emanando a classificação da conduta do agravado do exame das provas carreadas aos autos e das circunstâncias do delito, não pode esta Corte Superior proceder à alteração da conclusão firmada nas instâncias ordinárias sem revolver o acervo fático-probatório, providência incabível em recurso especial, consoante o óbice contido no verbete sumular n. 7/STJ. 5. Agrado regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1395205/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 5ª T., DJe 18/8/2014). Outros julgados neste sentido daquela Corte Superior: AgRg no REsp 257.642 - MG (2012/0244363-3) - neste precedente houve a apreensão de 377g de maconha e AgRg no REsp Nº 262.130 - MT (2012/0250605-3). Noutras palavras, entende-se que a quantidade e natureza da substância entorpecente, apesar de serem quase determinantes para a delimitação do destino da droga, por si só, não têm o condão de suprimir os demais critérios designados no § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 - local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente. Repisa-se, não foi encontrada nenhuma outra prova (balança de precisão, plásticos usados para individualizarem as drogas, anotações referentes ao tráfico etc.) que pudesse corroborar a imputação pela prática do tráfico de drogas pelo acusado. Corroborando a imputação de tráfico de entorpecentes, somente há a quantidade pequena de entorpecentes e as palavras confusas entre si dos policiais militares quando ouvidos em juízo acerca da abordagem do acusado. Por fim, necessário esclarecer: "vigora no sistema processual penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar" (STJ, HC 68.840/BA, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 28-04-2015). Por outro lado, não há como ignorar que a materialidade do delito ficou comprovada através dos autos de exibição e apreensão, do laudo de constatação, bem como do laudo de exame químico toxicológico. Porém, diante do escasso conjunto probatório reunido nos autos, verifica-se que permanece séria dúvida de que o réu é efetivamente traficante e que as poucas porções encontradas em seu poder se destinavam ao comércio ilícito. No processo criminal o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de ser o acusado o autor do fato criminoso. Deste modo, havendo dúvida quanto à natureza do fato, se para fins de tráfico ou uso próprio, resolve-se esta em favor dos agentes, diante da fragilidade do conjunto probatório e se considerando os parâmetros

previstos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para efeito de caracterização dos crimes nela previstos, a solução que se impõe, neste caso em especial, é a desclassificação da conduta do acusado para o tipo do art. 28 da citada lei. Passo à dosimetria das penas, levando em consideração os preceitos dos artigos 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. I. Com relação ao acusado FÁBIO, inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada da Suprema Corte não admite que a quantidade de drogas seja valorada negativamente na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, o que caracterizaria evidente e indevido bis in idem. A título de argumentação e de modo análogo, tampouco a personalidade do agente pode ser valorada negativamente na primeira e na terceira fases da fixação da pena, sob pena de duplo agravamento. Assinalo que, em sessão realizada no dia 19-12-2013, o Pleno do STF, ao julgar os HCs 112.776 e 109.193, ambos da relatoria do min. Teori Zavaski, firmou orientação no sentido de que, em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa. Na ocasião, ficou consignado que cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação ao bis in idem. [ARE 666.334 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 3-4-2014, P, DJE de 6-6-2014, repercussão geral, Tema 712.]. Desta forma, para evitar o bis in idem e antecipando o reconhecimento da figura do tráfico "privilegiado" (causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas), sopesarei as circunstâncias concretas quanto à quantidade das drogas (quanto à fração do redutor a ser aplicada) e para justificar a fixação de regime, deixando de considerá-las na primeira fase (artigos 59 do Código Penal e 42, da Lei nº 11.343/06). Nestes termos, nesta primeira fase, observo que a diversidade das drogas apreendidas com o acusado é gritante, não se olvidando do potencial lesivo ímpar de um dos entorpecentes com ele encontrado, qual seja, cocaína em forma de crack. Demais critérios se encontram dentro da normalidade. Em razão da circunstância judicial desfavorável, majoro as penas acima de seus patamares mínimos legais, elevando-as para 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no piso. Na segunda fase, forçoso o reconhecimento da atenuante da confissão e, com ela, retorno as penas para os seus mínimos legais, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário. Na terceira fase, a prova dos autos não é suficiente para comprovar o envolvimento do acusado com organização criminosa, nem para concluir, seguramente, que ele se dedique à prática reiterada do tráfico ilícito de drogas ou outros crimes. É certo que a Nova Lei de Drogas aperfeiçoou a sanção penal ao operar a distinção entre meros mercadores ocasionais, também merecedores de atenção do Estado, dos comerciantes de droga mais estruturados, verdadeiros empresários do tráfico. Distinção reclamada há muito tempo pelos aplicadores do Direito, tem por consequência a menor reprovabilidade da conduta do traficante ocasional e sua pena encontra fundamento e limite com a redução a integrar o tipo penal para os que apresentem as condições subjetivas típicas daqueles que não tenham estruturado envolvimento com o tráfico de drogas. No presente caso, entendo cabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Todavia, considerando a quantidade de drogas apreendidas com ele, entendo ser o caso de aplicar a redução na fração de $\frac{1}{2}$, diminuindo as penas para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso. Ausentes outras circunstâncias que alterem as penas, torno-as definitivas nestes patamares. O valor de cada dia-multa será no mínimo legal de 1/30 ao salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em razão das limitadas condições econômicas do réu (art. 43, da Nova Lei de Drogas). Tendo em vista a decisão do C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, que retirou o caráter de hediondez do tráfico privilegiado e afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado, o regime inicial de cumprimento de pena do investigado será o aberto em razão da quantidade da pena aplicada e atento aos critérios dos artigos 33, combinado com o artigo 59, ambos do Código Penal. No mesmo sentido, decidiu a C. Segunda Turma do STF: "Tráfico de entorpecentes: fixação do regime e substituição da pena. Não sendo

o paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59), a gravidade em abstrato do crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, não constitui motivação idônea para justificar a fixação do regime mais gravoso. Com esse entendimento, a Segunda Turma, após superar o óbice do Enunciado 691 da Súmula do STF, concedeu "habeas corpus" de ofício para garantir ao paciente, condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão pela prática do delito de tráfico de drogas, a substituição da reprimenda por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais, bem assim a fixação do regime inicial aberto. O Colegiado entendeu que o paciente atende aos requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual o juízo deve considerá-los ao estabelecer a reprimenda, de acordo com o princípio constitucional da individualização da pena. (HC 133028/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 12.4.2016. (HC-133028). Por isso, diante desses argumentos, entendo suficiente para a justa reprimenda a fixação de regime inicial prisional ABERTO. Embora ciente da nova orientação jurisprudencial, que admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendo que, no caso, a medida não se mostra suficiente e socialmente recomendada para o caso em tela. II. Com relação ao corrêu DIEGO, O art. 28, caput, prevê, em seus incisos, as penas de prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo e, ainda, advertência sobre os efeitos das drogas. Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu é reincidente. Outrossim, o réu assumiu a posse das drogas, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão. Atento às demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/2006, aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade por 2 (dois) meses. Todavia, considerando a prisão cautelar do acusado DIEGO, havendo já precedente desta Egrégia Corte (TJSP, Apelação Criminal nº 990.09.148618-3 Relator (a): Marco Nahum; Comarca: Birigüi; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 01/02/2010; Data de registro: 08/02/2010), entendo ser apropriada a compensação, a chamada "detração anômala", da pena ora imposta com o tempo em que o réu permaneceu preso preventivamente, operando a compensação no caso em tela e declarando, desde logo, EXTINTA a sua pena. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR: I. o acusado FABIO MAGALHAES DA SILVA, qualificado às págs. 18 e 59 às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicado o redutor legal previsto no §4º do referido artigo, e; II. o réu DIEGO NEVES DE SOUZA, qualificado à pág. 17, à pena de prestação de serviços à comunidade, pela prática da conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. 1. Com relação ao corrêu DIEGO, observo que a sua punibilidade restou extinta pelo cumprimento da pena, observando o quanto fundamentado acima. 2. Outrossim, considerando a fixação de regime aberto para um e a desclassificação e julgada extinta a pena para o outtro, os réus poderão recorrer em liberdade, neste ponto, não remanescendo os requisitos de suas prisões preventivas. EXPEÇAM-SE ALVARÁS DE SOLTURA. 3. Dê-se à droga apreendida a destinação prevista na Lei 11.343/06, autorizando desde já a incineração. 4. Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva do sentenciado FABIO, encaminhando-a ao juízo das execuções para o cumprimento da pena restritiva de direitos. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, intimando-o ao pagamento da pena pecuniária de multa, arquivando-se os autos. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. 5. Com relação ao sentenciado DIEGO, transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Comunique-se. Nada mais.

Após ser dada ciência do teor da r. Sentença proferida aos presentes, através de reunião audiovisual pela ferramenta Microsoft Teams, tem-se que, pela d. Representante do Ministério Público, não houve interesse em recorrer. Outrossim, os réus, após orientação dos seus d. defensores, e na ua presença destes, renunciaram ao direito de recorrer. Considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019),

dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, transitada em julgado a sentença, saiu o sentenciado FABIO ciente e intimado para efetuar o pagamento da pena de multa originária do crime no prazo de 10 (dez) dias contados desta data.

Pelo MM. Juiz foi dito que: 1. Certifique-se o trânsito em julgado. 2. Com relação ao sentenciado DIEGO, fica ratificada a EXTINÇÃO de sua punibilidade, pelo cumprimento da pena. Logo, após comunicações e ofícios de praxe, dê-se baixa na parte, arquivando-se os autos. 3. Com relação ao sentenciado FABIO, aguarde-se o seu comparecimento espontâneo em cartório por 10 (dez) dias. Comparecendo, expeça-se mandado de prisão de regime aberto e, com o seu cumprimento, expeça-se a competente guia de recolhimento definitiva do sentenciado, encaminhando-a ao juízo das execuções. Saindo ciente e intimado para o pagamento da pena de multa originária do crime, decorrido o prazo sem o devido pagamento, nos termos do Provimento CG nº 05/2022 desta E. Corte, o qual alterou os artigos 480 das NSCGJ, expeça-se certidão de sentença (Categoria 2, Modelo - 505791) e, em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, para fins do artigo 51 do Código Penal. Cadastrada a guia de recolhimento definitiva, expedida certidão de sentença e encaminhados os demais ofícios que, porventura, revelarem-se necessários, proceda-se ao lançamento da movimentação "Cód. 61619" e remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de estilo. Eventual pedido formulado pelo Ministério Público de declaração da extinção da punibilidade do sentenciado quanto à pena de multa em razão do valor irrisório, em que pese ser sua apreciação de competência do juízo da execução, face o princípio da economia processual, desde já HOMOLOGO, anote-se. No mais, cumpram-se as determinações dos §§ do art. 480 das NSCGJ. Com relação à taxa judiciária, proceda-se à inscrição em dívida ativa do Estado, na forma do art. 1.098 das NSCGJ. Em seguida, após comunicações e ofícios de praxe e de estilo, arquivem-se os autos.

Links dos arquivos audiovisuais:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EdzddC1iXuVIOHYH77jkjg0B4hrbhnOzqm5tmpfSPWg8pA
https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EfirhT2QGj1FLyQheuE6ebkBzxCauCdDAYfK_FOUMVhKFg
https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EZT5z5px5BtMhXhq8bXkLTMBV2MrCeTvESDFmfkdDHinxeg
https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EVpBtSVEcSBjp9absY1P0wgBmd_UvGFbATxF62p0qVRuXA
https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EVX_PGvOVkhIok4DPqHCn0cBhJYmd31iX_x5_cnfXhJUZA

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA